

1500399-47.2019.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... um efetivo envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-47.2019.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-47.2019.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2303073/2019 - DEL.POL.CONCHAL, 8045204 - DEL.POL.CONCHAL, 1491/19/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2303073 - DEL.POL.CONCHAL, 1491/19/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2303073 - DEL.POL.CONCHAL, 1491/19/801 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN MIGUEL DE JESUS VIVALDINI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

ALLAN MIGUEL DE JESUS VIVALDINI, qualificado à fls. 32/33, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 17 de outubro de 2019, às 00h30min, na Rua Manacás, nº 1113, Bairro Benedito Novo, neste Município e Comarca de Conchal, agindo em concurso com o adolescente K. V., guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção não fracionada de maconha, com peso aproximado de 446 gramas (quatrocentos e quarenta e seis gramas).

Notificado às fls. 75/76, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 83/87.

A denúncia foi recebida em 20 de março de 2020 (fl. 88).

Em audiência de instrução e de continuação, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

A d. Representante do Ministério Público manifestou-se oralmente, conforme gravação audiovisual.

A i. Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva
É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 18/19, indicador de que o acusado tinha em depósito uma porção de maconha, com massa bruta de 446g (quatrocentos e quarenta e seis gramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 207/209, está comprovado que a substância apreendida com o acusado era "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2". Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha guarda municipal Mauricio Aparecido Viola relatou que estava em patrulhamento quando recebeu um telefonema solicitando apoio em abordagem no bairro Esperança I. Dirigiu-se ao local, onde encontrou o adolescente K., já apreendido, pois estaria negociando uma porção de maconha com Allan, por mensagens de Whatsapp. Foram até a residência de Allan na rua dos Manacás, e ao tocar a campainha, o acusado saiu da residência, com a porção de drogas que entregaria ao adolescente K. O acusado se surpreendeu com a presença da viatura e jogou a droga no chão. Em buscas pela residência, também foram apreendidos a quantia de R\$271,00 (duzentos e setenta e um reais) e dois celulares. Confessou ao policiais que venderia as drogas ao adolescente K.

Interrogado em juízo, Allan Miguel de Jesus Vivaldini disse que estava negociando a droga com seu primo, com quem fazia uso em conjunto. Comprou 500g (quinhentos gramas) e pagou R\$500,00 (quinhentos reais). Seu primo insistiu que queria comprar a droga, pelo valor de R\$700,00 (setecentos reais).

Em audiência em continuação, o policial militar Leandro Laurindo da Silva relatou que estava em patrulhamento por local conhecido pelo tráfico de drogas. Avistaram um adolescente em atitude suspeita, comprando um lanche. Feita a abordagem, localizaram com o adolescente uma pequena porção de entorpecente. O adolescente indicou o cômodo onde estava. No local, havia uma pia, um fogão, um celular carregando, além de tesoura e vários invólucros. Durante a diligência, percebeu o recebimento de mensagens no celular, dentre elas, uma foto de entorpecente. Viu ainda a conversa que consistia em transação sobre a compra de drogas, cuja venda posteriormente se daria naquele local. Conhecia o interlocutor da conversa que se identificou como Allan. Dirigiu-se até a casa de Allan, e o chamou no portão. Ele saiu da residência, acreditando que seria o adolescente K. Ele assustou ao ver a guarnição policial e deixou a sacola de droga cair perto do portão. Ainda, dentro da residência, encontrou dinheiro trocado.

Renovado o interrogatório, o réu Allan Miguel de Jesus Vivaldini disse que o dinheiro e a droga lhe pertenciam. No entanto, a droga não se destinava ao tráfico. Alegou que sempre trabalhou e estudou. O tijolo de maconha era para seu consumo próprio. Seu primo lhe perguntou se tinha drogas. Estava em situação financeira

difícil, então resolveu vender a droga por R\$700,00 (setecentos reais). Às perguntas do juízo respondeu que comprou a droga de um amigo. Disse que pagou barato, parcelado. Comprou a droga havia dois dias, por R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais) e resolveu vender.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu, de que é apenas usuário de entorpecentes não é suficiente a operar a desclassificação para o delito do artigo 28, LD. Mesmo que o réu também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço, pelo que não prospera a solução desclassificatória. .

Ademais, o réu admitiu expressamente que comprou a droga e, dois dias após, pretendia vender ao seu primo, com lucro significativo. Tal admissão da culpa é suficiente a caracterizar o ato de traficância. Por oportuno, cumpre ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar - sendo necessário a prática de apenas uma dessas condutas para consumar o delito em tela.

Ademais, as palavras dos agentes de segurança, servidores públicos ouvidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a variedade e a forma de acondicionamento, se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga, em quantidade significativa, evidenciando um efetivo envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu deve ser considerado tecnicamente primário (fls. 40/42). As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a considerar. Por outro lado, ainda que a confissão qualificada do réu, de que praticou a venda do entorpecente, tenha sido utilizada na fundamentação para o decreto condenatório, a circunstância atenuante não pode conduzir a pena a quem do patamar mínimo legal, nos termos da súmula 231, STJ. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, aplico o redutor inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e não há provas de que integra, de fato, organização criminosa. Assim, faz jus ao redutor na fração legal de 2/3 (dois terços), definindo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. De outra parte, impõe-se a incidência da causa prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 uma vez que amplamente demonstrado nos autos o envolvimento do adolescente K. V. na transação ilícita, tendo o réu admitido que negociou a venda da droga ao adolescente pelo valor de R\$700,00 (setecentos reais). Dessarte, majoro a reprimenda na fração legal de 1/6 (um sexto), tornando definitiva a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À míngua de outros elementos, é de rigor a fixação do mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

A Resolução nº 5/12 do Senado Federal suspendeu a execução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Nessa medida, verifico a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal, nos termos dos incisos II e III, pois a culpabilidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente ao réu. Faz jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação de serviços à comunidade ou à entidade cadastrada pelo Juízo, pelo prazo da pena cominada, e a limitação de fim de semana, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Em caso de descumprimento da pena substituída, fixo o regime inicial aberto.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR ALLAN MIGUEL DE JESUS VIVALDINI qualificado à fls. 32/33, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto na pena substituída e limitação de fim de semana, sendo que o local e modo de cumprimento serão indicados pelo D. Juízo das Execuções.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Encerrada a instrução e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento das penas.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade(art. 105 da Lei nº 7.210/84);
- 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;
- 6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA